

1500682-65.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... ao crime de associação para o tráfico e condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fixação da pena-base acima do mínimo legal e regime inicial fechado para início do desconto da pena.

A Defesa pugnou pela improcedência da ação penal em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, bem como pela desclassificação, em relação a ambos os réus, do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis-Foro de Assis-2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500682-65.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500682-65.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080775/2022 - DEL.POL.TARUMA, 23817730 - DEL.POL.TARUMA, 2080775 - DEL.POL.TARUMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GUSTAVO HENRIQUE PRADO DA CUNHA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

DIEGO LUCIANO FERRARI DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE BENEDITO PIMENTA foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do concurso material de delitos (artigo 69, do Código Penal), porque:

I - No dia 23 de março de 2022, por volta das 18:20 h, na Avenida Tarumã, nº 406, na Cidade de Tarumã, nesta Comarca de Assis, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 8 porções de cocaína, com o peso total aproximado de 114 gramas, e 5 porções de maconha, com o peso total aproximado de 6,55 gramas;

II - Além disso, ao menos até o início da noite de 23 de março de 2022, os réus associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente ou não o crime de tráfico de substância entorpecente.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou DIEGO e MATHEUS associaram-se para, de maneira estável promoverem o tráfico de drogas e, no início da noite de 23 de março de 2022, traziam consigo as drogas acima mencionadas, quando avistados pelos policiais no interior do

veículo Safira, cor preta, de propriedade de DIEGO.

Ocorre que a prática dos denunciados chegou ao conhecimento da polícia militar, através de denúncia anônima, que passou a realizar patrulhamento pelas proximidades do local e avistaram os denunciados no interior do referido veículo conduzido por DIEGO, tendo MATHEUS como passageiro.

Dada a suspeita fora determinada a parada do veículo, ocasião em que DIEGO entregou algo para MATHEUS, que por sua vez desceu do carro e empreendeu fuga a pé, correndo da viatura policial e carregando o pacote nas mãos.

Perseguido pelos policiais, MATHEUS foi avistado dispensando o pacote em um terreno baldio, localizado na Rua das Acácias, próximo ao numeral 313, sendo abordado a aproximadamente cinco quarteirões do referido local.

Realizada a captura de MATHEUS, os policiais retornaram até o terreno baldio e identificaram o pacote dispensado como sendo um saco branco, que dentro acondicionava vários plásticos do tipo zip lock e grande porção de cocaína.

Enquanto isso, o veículo conduzido por DIEGO fora perseguido por outra viatura de apoio e abordado no cruzamento da Rua São Paulo com Rua Alagoas.

Em revista ao carro conduzido por DIEGO localizaram, perto do console, no câmbio do carro, cinco saquinhos com cocaína em pó, um saquinho a granel com três pelotas de cocaína e cinco trouxinhas de maconha.

Ainda, em posse de DIEGO, os policiais localizaram R\$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das porções de drogas, somadas às informações previamente recebida pelos policiais militares, não dão outra ideia senão a de que DIEGO e MATHEUS, associados, promoviam o tráfico de drogas nos locais dos fatos.

Notificados (fls. 239 e 241), os réus apresentaram defesas prévias (fls. 250/251 e 253/255). A denúncia foi recebida (fl. 266/268).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e os réus (fls. 372/373).

As partes se manifestaram em alegações finais orais. O Ministério Público pugnou pela absolvição dos réus em relação ao crime de associação para o tráfico e condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fixação da pena-base acima do mínimo legal e regime inicial fechado para início do desconto da pena.

A Defesa pugnou pela improcedência da ação penal em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, bem como pela desclassificação, em relação a ambos os réus, do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para consumo. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime compatível com a pena aplicada, direito de recorrer em liberdade e liberação do dinheiro e veículo apreendidos.

II - Fundamentação

A ação penal procede apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, em relação a ambos os réus, como passo a demonstrar.

Com efeito, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelo laudo toxicológico (fls. 173/175), que testou positivo para Cocaína e Tetrahydrocannabinol, substâncias catalogadas como drogas pela Portaria 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral.

Nesse sentido, o policial militar Jailson Oliveira dos Santos afirmou em sede extrajudicial que, na data dos fatos, receberam informação de um popular no sentido de que DIEGO iria embalar grande quantidade de droga recebida na Rua Bahia, nº 269. O local de embalo seria o bar pertencente a DIEGO. Então, foram até o local a fim de realizar patrulhamento, já sabendo que DIEGO é proprietário de um veículo Zafira, cor preta. Avistaram referido automóvel e realizaram sinal de parada.

Naquele momento, o veículo era conduzido por DIEGO e tinha como passageiro a pessoa de MATHEUS, vulgo "Cascão". Visualizou DIEGO entregando algo a MATHEUS, o qual desceu do carro e empreendeu fuga a pé. MATHEUS correu carregando um pacote na mão, razão pela qual realizaram seu acompanhamento. O veículo de DIEGO foi acompanhado pela viatura de apoio, do Sargento Marcela e do Cabo Medalha. Na sequência, em acompanhamento a MATHEUS, visualizou quando ele dispensou algo no terreno baldio e

continuou correndo, somente sendo abordado a 5 quarteirões do local. Em revista pessoal, nada foi localizado com MATHEUS. Retornaram ao terreno onde MATHEUS dispensou o pacote e localizaram um saco branco contendo plásticos zip lock e uma grande porção de cocaína. Sobre o veículo Zafira, soube que a equipe procedeu à abordagem e localizou droga. Foram até o local que a informação apontava que DIEGO teria pego a droga para embalo, onde foram atendidos por Gustavo, o qual confirmou que DIEGO esteve lá e pediu saquinhos do tipo zip lock. Segundo Gustavo, DIEGO disse que usaria os saquinhos para embalar drogas.

Em juízo, disse que, na data dos fatos, estava de serviço com o Cabo Muniz, quando receberam denúncia diretamente à equipe de que os réus estariam com uma grande quantidade de droga e iriam embalar no bar de DIEGO. Em patrulhamento, localizaram o carro de DIEGO e deram ordem de parada. DIEGO passou a droga para MATHEUS, o qual saiu correndo, tendo sido possível visualiza-lo jogar a droga num terreno. Após 5 quarteirões conseguiram deter MATHEUS, o qual desconversou falando que não tinha droga. Localizou no terreno baldio a droga dispensada por MATHEUS. A outra equipe abordou DIEGO próximo à casa dele e encontrou mais droga. Como a denúncia dava conta de que MATHEUS teria ido até a Rua Bahia, na casa de Gustavo, foram até a casa deste, o qual asseverou que os réus foram lá com as drogas em mãos e entregou a eles 5 saquinhos. Gustavo franqueou a entrada na residência, onde não localizaram nenhum ilícito. Gustavo disse que era usuário de maconha. Quando viu DIEGO passar a droga para MATHEUS, estava praticamente ao lado dele. Não era o condutor da viatura. DIEGO fugiu do local e foi preso por outra equipe. A perseguição a MATHEUS durou uns 4 ou 5 minutos. A droga foi encontrada num terreno baldio, no meio do mato. Não presenciou a abordagem da outra viatura, pois realizou o acompanhamento de MATHEUS, o qual, a princípio, negou que a droga fosse dele, mas o presenciou jogar a droga no terreno. Após, ele disse que havia jogado a droga no bueiro. A substância estava numa porção só. O Cabo Muniz era quem o acompanhava na diligência e, na outra equipe, estavam o Cabo Medalha e a Sargento Marcela. Durante a fuga, MATHEUS ficou a todo tempo sob sua visão, não o tendo perdido de vista. O policial militar Anderson Muniz Cardoso apresentou, em sede policial, relato idêntico ao de seu companheiro de farda Jailson, acrescentando que encontrou no veículo de DIEGO, no câmbio do carro, 5 saquinhos com cocaína em pó, 1 saquinho a granel com 3 pelotinhas de cocaína e 5 trouxinhas de maconha. DIEGO disse que era usuário.

Em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento e receberam denúncia de que DIEGO ia pegar uma quantidade de droga e levaria para a casa de Gustavo. Havia denúncias de que DIEGO fazia o tráfico em seu bar, na Rua dos Cravos. Naquela tarde, viram DIEGO saindo da casa de Gustavo, numa Zafira, e foram atrás dele. Próximo à base da polícia militar, foi dada ordem de parada e, próximo à lotérica, ele parou o veículo e passou a droga para MATHEUS, o qual saiu correndo. Naquele momento, deixaram DIEGO e foram atrás de MATHEUS, que jogou o objeto e seguiu correndo. Conseguiram abordá-lo, tendo MATHEUS dito que era usuário e não tinha nada. Voltaram ao local em que MATHEUS havia dispensado um objeto, tendo localizado cocaína e saquinhos. Duas viaturas o apoiaram e conseguiram abordar DIEGO, com quem encontraram mais algumas porções de droga. Então, realizaram a prisão dos réus. Foi feito contato com Gustavo, o qual disse que era somente usuário e estava guardando na casa alguns saquinhos ziplock para DIEGO. Já havia várias denúncias em relação a DIEGO, sendo seu bar conhecido como ponto de tráfico de drogas. MATHEUS andava sempre com DIEGO. A denúncia de que DIEGO ia embalar a droga foi presencial (não anônima). Não se recorda quantos saquinhos tinham, mas com certeza mais de 100. Estavam do lado do carro de DIEGO quando o abordaram e fecharam o carro dele. Porém, optaram por perseguir MATHEUS, já que era quem trazia algo consigo. Não viu a abordagem de DIEGO. Não se recorda se Gustavo falou se MATHEUS estava com DIEGO quando este esteve em sua casa, mas pode dizer que sim, pois a casa de Gustavo é perto do batalhão e de lá viram os dois no carro.

A policial militar Marcela relatou em juízo que efetuou a abordagem de uma pessoa de nome DIEGO dentro de um veículo Zafira, após pedido de apoio de outra viatura. Foi feita vistoria veicular, tendo sido encontrada porção de maconha e cocaína, além de dinheiro. Apenas abordou o veículo, quem deu continuidade foi o pessoal da

outra equipe. A mesma equipe que pediu o auxílio foi a que encontrou a droga com DIEGO.

O policial militar Medalha disse em juízo que, após pedido de auxílio, foram abordar o carro de DIEGO, o qual, quando chegou, já estava sendo abordado por outra equipe. Após informação de que os réus teriam pego pacotes na casa de Gustavo, dirigiu-se até a residência dele. Conversaram com Gustavo, o qual relatou que os réus foram até a casa dela a fim de pegar um pacote vazio. Ele franqueou a entrada, mas nada de ilícito foi localizado. Gustavo não mencionou se os réus tinham droga em sua posse. No carro que foi abordado, foram localizados alguns pacotinhos de droga por outra equipe. Quando da abordagem, o rapaz afirmou que era usuário. Quando chegou ao local, DIEGO já estava sendo abordado por uma outra equipe, que não era a mesma que abordara MATHEUS. DIEGO tinha dinheiro na posse dele, em notas de R\$ 100,00, R\$ 50,00 e de R\$ 20,00, se não lhe falha a memória, mas não recorda o valor total.

A testemunha Gustavo Henrique Prado da Cunha disse em sede policial que no domingo anterior à data dos fatos foi seu aniversário, tendo comemorado na segunda-feira com algumas pessoas, dentre elas DIEGO, o qual lhe pediu para guardar 3 saquinhos ziplock, vazios, pois estava com medo que a polícia o abordasse e encontrasse os objetos. DIEGO não ofereceu nenhum dinheiro para que guardasse, tendo aceitado porque não viu nada de errado. Levou os saquinhos para sua casa e deixou por lá. Na data dos fatos, DIEGO mandou mensagem e disse que passaria em sua residência para pegar os saquinhos. Então, DIEGO foi com MATHEUS para sua casa, os quais pegaram os saquinhos e disseram que iriam para a casa do primeiro embalar drogas. A polícia chegou em sua residência depois, afirmando que havia detido DIEGO e MATHEUS, perguntando sobre existência de balança no local. Autorizou o ingresso dos policiais em sua casa, que não localizaram nenhum ilícito. Não tem vínculo com o tráfico.

Em juízo, afirmou que conhece os réus. Declarou que, na data dos fatos, os réus passaram em sua casa, onde apenas fumaram um baseado e foram embora. Não entregou nada para eles naquele dia. DIEGO não disse que iria embalar droga. Não disse à polícia que eles estavam com droga. Não se recorda do depoimento que deu em sede policial. Não leu seu depoimento na delegacia de polícia. Não disse aos policiais que viu DIEGO com uma sacola branca. Não sabe dizer por qual razão teria constado em seu depoimento de sede policial algo que não teria dito. Assinou seu termo de depoimento feito na delegacia, mas não leu. Foi muito pressionado pelos policiais militares naquele dia, pois estava sozinho em casa. Dr. Sérgio foi advogado de sua irmã há certo tempo, tendo sua mãe o contratado. Não tem nenhuma razão para mentir. Foi pressionado pela polícia em sua casa e na delegacia, pois eles falavam que seria preso, o ameaçando. Não disse aos policiais que os réus teriam passado em sua casa para pegar saquinhos. Enquanto conversava com o delegado, haviam dois policiais militares na sala ouvindo seu depoimento, afirmando que eram o policial Medalha e também a sargenta. Reafirmou que não disse aquilo que consta de seu termo de depoimento em sede policial, pois não leu o que assinou.

A testemunha de defesa Gabriela Carolina Gomes Torreti afirmou em juízo que conhece DIEGO, pois tem uma lanchonete, onde ele frequentava. Não é amiga íntima dele. Conhece ele desde que abriu a lanchonete, há cerca de 1 ano, 1 ano e meio. Via ele todos os dias, pois ele passava, pegava um pastel para o filho, pegava um refrigerante e ia embora. Sempre via ele de uniforme, sabendo que ele trabalhava na FEMA de ajudante geral. Ele já foi à noite com a mulher e com o filho. Não sabe se ele tem bar em Tarumã.

A testemunha de defesa Cristina Aparecida Ferreira afirmou em juízo que conhece MATHEUS, asseverando que ele é seu vizinho. Sabe que ele foi "enquadrado com produtos ilícitos", mas não presenciou os fatos. Disse que ele é trabalhador e dedicado à família. Sabe que ele é usuário de droga.

O informante Douglas Henrique Ferrari da Silva declarou em juízo que é irmão de DIEGO. Afirmou que a abordagem foi próxima à casa de seu avô. Acompanhou toda a abordagem e naquele momento viu que tinha um policial filmando ele e pedindo para contar o dinheiro, não tendo visto nenhuma voz de prisão. Quando chegou, o réu estava saindo do carro. Havia no local um policial homem e uma policial mulher.

Ninguém falou nada se havia encontrado algo no carro dele. O carro que ele estava usando foi comprado por si e por seu pai, sendo que eles usavam para trabalhar. DIEGO faz serviços gerais na FEMA. Ele tinha um bar em Tarumã bem antes da prisão, ele já tinha vendido o estabelecimento. Conhece MATHEUS de vista só. DIEGO tem um filho de dois anos. Não viu apreensão de droga do carro dirigido por seu irmão. Não sabe se ele estava na casa de Gustavo naquele dia, pois estava na casa de seu vô. Não sabe se DIEGO estava com MATHEUS naquele dia.

Interrogado, o acusado DIEGO afirmou em sede policial que, na ocasião, estava de folga do trabalho, razão pela qual lavou o carro e estava dando uma volta pela cidade. Encontrou "Cascão", vulgo corréu, seu conhecido, o qual lhe pediu carona. Estavam com um "beck" e, então, foram para a casa de Gustavo e lá "deram um trago". Após sair da casa de Gustavo, foram abordados pela polícia. Parou o carro e colocou as mãos pra cima, momento em que percebeu que MATHEUS havia corrido. Estava na posse de um baseado apenas. Em seguida, a primeira viatura retornou com MATHEUS no guarda preso. Tinha R\$ 500,00 em sua carteira, proveniente do saque de R\$ 660,00 que realizou na mesma data. Já tinha gastado R\$ 160,00. Nenhuma droga, com exceção do baseado, foi encontrada em seu carro ou em sua posse. Só ficou sabendo que o corréu estava com droga quando chegou na delegacia. Só viu o corréu com um baseado. Sabe que MATHEUS é usuário de pó. Conhece Gustavo, pois este anda de skate e fuma "beck". Não pegou nada com Gustavo, apenas foi na casa dele para fumar maconha. Se soubesse que MATHEUS estava com droga, tinha "dado um pau nele" e nem tinha dado carona.

Em juízo, declarou que trabalhava na FEMA, na parte geral, como ajudante de servente, bem como na parte de ferragem. Era uma empresa terceirizada que lhe pagava. Respondeu por fato análogo ao tráfico quando era menor de idade. Negou os fatos, afirmando que estava de folga naquele dia. Lavou o carro e ficou andando pela cidade. À tarde, estava andando perto da mina, quando encontrou MATHEUS, que lhe pediu carona. Passaram na rua do Gustavo, que estava sentado no portão da casa dele, onde pararam e fumaram um cigarro de maconha. Após terem saído da casa do Gustavo, passou pela rua do batalhão da polícia e foi abordado. Parou o carro e MATHEUS correu, tendo ficado confuso. Os policiais foram atrás de MATHEUS e outros policiais procederam à sua abordagem. Tinha R\$ 500,00 no bolso, tendo o policial pedido para contar o dinheiro. Quinze minutos depois outra viatura chegou com MATHEUS no guarda preso. O policial Muniz desceu e falou "sua casa caiu", perguntando se tinha algo de ilícito. O policial pediu para contar o dinheiro e pegou o celular para filmar. Contou o dinheiro e guardou na carteira de novo. O policial revistou seu carro e filmou, tendo ido na casa do Gustavo depois. Após terem ido à casa do Gustavo, eles voltaram dizendo que teria que ir até a delegacia. Na delegacia que foi saber a razão de MATHEUS ter corrido. Se soubesse que ele estava com droga, não teria dado carona a ele e não teria passado pela rua do batalhão da polícia. Em seu carro não foi localizada nenhuma droga, a única coisa que estava consigo era a maconha. Estava com "3 parangas" no bolso. Na hora que foram abordados, somente foi fazer o balão para voltar, não tentou se evadir. Não passou droga nenhuma para MATHEUS, nem tinha ciência que ele tinha droga. Teve um bar em Tarumã por três anos, o qual foi abordado várias vezes por policiais. É usuário de maconha. O carro que estava usando pertence a seu pai e seu irmão. O dinheiro que foi apreendido consigo era de seu vale.

O réu MATHEUS relatou em sede policial que, na data dos fatos, comprou um "caroço" de cocaína para fazer uso, pelo valor de R\$ 1.200,00. Realizou a compra sozinho e estava subindo a rua a pé, quando seu amigo DIEGO lhe deu carona até a casa de Gustavo, onde todos fumaram um baseado. DIEGO disse que o deixaria em casa, quando saíram da residência de Gustavo e foram abordados pelos policiais. Quando a polícia deu ordem de parada, DIEGO parou o veículo imediatamente. Ficou apavorado porque estava alucinado por conta do baseado que fumou, e como estava com o "caroço" de cocaína, resolveu correr a pé, momento em que arremessou a droga num terreno. Após correr, foi alcançado pelos policiais que o revistaram e nada localizaram. Afirmou que não havia drogas no carro de DIEGO. Tomou conhecimento do encontro de outras porções de droga na delegacia. Apenas o "caroço" maior era de sua propriedade. Em juízo, negou os fatos. Afirmou que é usuário e dependente químico. Tinha

comprado a cocaína para seu uso. Próximo à casa de Gustavo, encontrou DIEGO e pediu carona a ele. Pararam na casa de Gustavo e fumaram um cigarro de maconha, tendo ido embora na sequência. Afirmou que, então, foram abordados. DIEGO não sabia que estava com drogas, tendo se apavorado e corrido na hora. Foi seguido pela viatura do policial Muniz, que o abordou e localizou a cocaína. Após, foi levado para onde DIEGO estava sendo abordado e o deixaram na viatura. Não entendeu a razão de DIEGO estivesse com droga, provavelmente não teria parado. Não é verdade que DIEGO lhe passou a droga, ele nem sabia que estava com os entorpecentes. Encontrou o DIEGO uma três ruas antes da casa do Gustavo. O batalhão da polícia fica a uns seis quarteirões da casa de Gustavo. Os policiais estavam dentro da viatura quando deram ordem de parada, tendo DIEGO parado o carro e os policiais pararam atrás. Tinha uma porção de cocaína relativamente grande consigo. A maconha não foi encontrada consigo. Não tinha dinheiro. Usa droga todo dia, cerca de 30 ou 40 gramas. Paga cerca de R\$ 1.200,00 em porções de 125 gramas. Ganha R\$ 2.640,00 na carteira, mas ganha mais dinheiro por fora, totalizando R\$ 4.800,00 mensais. Comprou a cocaína apreendida naquele dia. Foi abordado 18:00h, tinha acabado de sair do serviço, passou no banco e foi comprar droga. Não pegou nenhuma sacola na casa de Gustavo e nem viu ele entregando nada para DIEGO. Comprou a cocaína e já usou parte imediatamente. A droga não atrapalha seu trabalho.

Pois bem. O quadro é suficiente ao acolhimento da pretensão apenas no que tange ao crime de tráfico de drogas, perpetrado por ambos os réus.

Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Os policiais asseveraram em juízo que, na ocasião, receberam informação de que DIEGO embalaria droga no bar dele, razão pela qual se deslocaram ao local a fim de realizar patrulhamento e eventual abordagem. Em dado momento, visualizaram o veículo de DIEGO, o qual estava na condução, com MATHEUS de passageiro. Após sinal de parada, visualizaram DIEGO entregando algo a MATHEUS, o qual desceu do carro e empreendeu fuga, dispensando um pacote num terreno baldio. Posteriormente, abordaram MATHEUS e retornaram ao terreno baldio, onde localizaram um saco branco que continha plásticos ziplock e uma grande porção de cocaína. Enquanto isso, outra equipe procedeu à abordagem do veículo de DIEGO, tendo localizado mais droga no interior do carro, sendo 5 saquinhos com cocaína em pó, 1 saquinho a granel com 3 pelotinhas de cocaína e 5 trouxinhas de maconha. Na sequência, foram até o local onde a informação apontava que DIEGO teria pego a droga, tendo sido atendidos por Gustavo, o qual asseverou que DIEGO esteve lá e pediu saquinhos ziplock, afirmando que os utilizaram para embalar droga.

Por outro lado, o réu DIEGO se limitou a dizer que, naquele dia, estava de folga e foi dar uma volta de carro pela cidade, quando encontrou o corréu MATHEUS, para quem deu carona, tendo ambos ido até a casa da testemunha Gustavo a fim de fumar maconha. DIEGO afirmou que somente tinha "três parangas" de maconha no bolso, que não havia drogas em seu carro e que não sabia que MATHEUS estava na posse de cocaína.

Já MATHEUS asseverou que comprou uma porção de cocaína para seu próprio consumo, tendo pago R\$ 1.200,00 pela droga. Relatou que estava subindo a rua quando DIEGO passou de carro e lhe deu carona até a casa de Gustavo, onde fumaram maconha. Salientou que ficou apavorado com a abordagem policial e tentou empreender fuga, tendo jogado a porção de cocaína que comprou num terreno baldio.

Contudo, as versões apresentadas pelos acusados não se mostraram verídicas. Isso porque, como visto, a testemunha Gustavo declarou em sede policial que, dias antes dos fatos, DIEGO lhe pediu para guardar saquinhos ziplock e, pouco antes da

abordagem policial, ele foi até sua casa com MATHEUS, onde pediram que entregasse os saquinhos, dizendo que embalaria drogas com os petrechos.

É certo que, em juízo, não se sabe por qual razão, a testemunha Gustavo alterou a versão dos fatos, tendo dito que, na realidade, os réus somente passaram em sua casa, onde fumaram maconha, não tendo guardado para eles saquinhos plásticos, asseverando que assinou o termo do depoimento dado na delegacia sem ler o conteúdo, pois foi pressionado pelos policiais.

Porém, depreende-se de fl. 12 que o depoimento prestado em sede policial foi presenciado apenas pelo delegado e pelo escrivão de polícia, de sorte que não se vislumbra nenhuma razão para que tais agentes públicos falsificassem o teor do que foi declarado pela testemunha Gustavo naquela oportunidade. E mais, a alegada pressão sofrida pelos policiais que fizeram contato com a testemunha não pode servir de fundamento para o alegado fato de ter assinado o termo sem ler, porquanto, repita-se, o depoimento foi realizado apenas na presença do delegado e do escrivão de polícia.

E mais. O laudo pericial de fls. 395/401, realizado em relação ao aparelho celular apreendido com DIEGO, revelou o seguinte diálogo que este manteve com a testemunha Gustavo na data dos fatos:

17:42h - Gustavo: Quantos ziploc?

17:43h - Diego: Pode por 300

17:43h - Diego: Já já eu passo pega

17:43h - Diego: Tô com meu filho vou leva ele embora

17:43h - Gustavo: Demoro

17:43h - Gustavo: Só dá um salve

18:12h - Diego: Ou

18:12h - Diego: *áudio não transcrito*

18:13h - Gustavo: Se esperar 4 minutos

18:13h - Gustavo: Eu tiro

18:13h - Gustavo: Pera aí vô tirar

18:13h - Gustavo: Kk

18:13h - Diego: *áudio não transcrito*

18:14h - Gustavo: Pdc

18:14h - Gustavo: *áudio não transcrito*

18:16h - Diego: *áudio não transcrito*

18:16h - Gustavo: Tá no oente

18:16h - Gustavo: Pente

18:16h - Gustavo: Cola

18:16h - Gustavo: Tinha um zip lox

Desse modo, reputo que, realmente, a versão de Gustavo apresentada em sede policial, frise-se, no dia dos fatos, não pode ser desconsiderada, devendo o relato feito em juízo, ao contrário, ser visto com ressalva, especialmente ao se considerar o conteúdo das mensagens transcritas, as quais revelam, de fato, que a testemunha guardava saquinhos para DIEGO.

Não bastasse o que foi dito por Gustavo em sede policial, a tentativa de fuga de MATHEUS, inclusive com a dispensa de uma porção relevante de cocaína em terreno baldio, revela que a droga não seria destinada em consumo próprio, e sim à traficância.

Aliás, não obstante MATHEUS ter dito que sacou dinheiro no banco naquela mesma data e, após, comprou a droga para seu uso, tal alegação, que seria de fácil comprovação, bastando a juntada de extrato bancário, não foi demonstrada nos autos. Além disso, a despeito das versões apresentadas pelos policiais no sentido de que localizaram drogas no veículo de DIEGO, este se restringiu a afirmar que somente estava na posse de "três parangas" de maconha, não sabendo que MATHEUS estava com cocaína, narrativa que não se coaduna com o que foi dito pelos agentes públicos, nem encontra confirmação no relato da testemunha Gustavo, o qual, como dito, asseverou que os réus lhe disseram que embalaria drogas.

Aliás, como visto, os policiais asseveraram em sede administrativa e em juízo que visualizaram DIEGO repassando a droga para MATHEUS, o qual, na sequência, empreendeu fuga à pé e dispensou o entorpecente no mato, circunstância que, por si

só, revela que DIEGO não apenas tinha ciência da existência da droga, como a passou para o corréu fugir com a substância.

Não é ocioso destacar, ainda, que não há nos autos qualquer indício de que os policiais militares, bem como a testemunha, ouvidos em sede policial e em Juízo, desejassem incriminar os réus injustamente.

Ademais, a procedência lícita do dinheiro apreendido junto a DIEGO não restou demonstrada. Com efeito, apesar de o acusado ter afirmado que os R\$ 500,00 eram provenientes de saque bancário efetuado naquela mesma data, não há nos autos nenhum comprovante do alegado, o que indica que a quantia foi obtida com a traficância. Destarte, restou suficiente comprovado que, na realidade, DIEGO e MATHEUS traziam consigo drogas no veículo, de modo que, sendo considerável sua quantidade e não havendo comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido, não há falar em destinação dos entorpecentes ao próprio consumo.

Não se ignora a condição de usuários dos réus. Contudo, tal circunstância não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não sendo ocioso destacar que não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de entorpecentes.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava à traficância, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Contudo, não prospera o tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.

De fato, não há provas de que os acusados se uniram, de maneira estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo elementos para se concluir que a situação se apartara de mero concurso de agentes, pseudo-concurso, insuscetível de configuração de crime autônomo. Não basta que duas pessoas pratiquem juntas o tráfico de drogas para incidirem em tipo autônomo, na medida em que o núcleo do tipo é associarem-se, que denota, por sua semântica, os elementos da estabilidade e permanência, imprescindíveis à tipicidade formal.

Portanto, apenas o ajuste entre dois ou mais indivíduos que se estabiliza é que permite a incidência do art. 35, ainda que as tratativas duradoras sejam para a prática de um único crime de tráfico de drogas; motivo pelo qual a lei vale-se da expressão "reiteradamente ou não". Nesta direção, e.g, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06 (REsp. 1.113.728/SC, Min. Rel. Felix Fischer, 5ª T., j. 29.09.2009) (destaquei).

Destarte, impõe-se o desacolhimento da pretensão, nesse particular.

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiram em fatos típicos (que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídicos, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

DIEGO LUCIANO FERRARI DA SILVA

Na primeira fase, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas(cocaína e maconha) justificam o reconhecimento de maior censurabilidade da conduta, o que ocasionaria a intensificação da pena já na primeira fase. Entretanto, tais circunstâncias serão sopesadas na terceira fase da dosimetria para fins de modulação do redutor. Assim, a fim de evitar o bis in idem, deixo de aumentar a pena neste primário estágio, razão pela qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena intermediária se mantém em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena, incidindo, entretanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto o sentenciado é primário, não ostenta maus antecedentes e, ademais, inexistente prova de que se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Não desconsidero que o sentenciado cumpriu medidas socioeducativa por maus antecedentes. Entretanto, segundo orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as anotações relativas a atos infracionais não obstam a incidência do redutor em questão. Assim, considerada a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, reputo adequada a redução da pena na fração de 1/2, tornando definitiva a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

MATHEUS HENRIQUE BENEDITO PIMENTA

Na primeira fase, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) justificam o reconhecimento de maior censurabilidade da conduta, o que ocasionaria a intensificação da pena já na primeira fase. Entretanto, tais circunstâncias serão sopesadas na terceira fase da dosimetria para fins de modulação do redutor. Assim, a fim de evitar o bis in idem, deixo de aumentar a pena neste primário estágio, razão pela qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena intermediária se mantém em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. De outro modo, não havendo prova de que o sentenciado seja reincidente, tenha envolvimento com organização criminosa ou se dedique a tais atividades, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, que autoriza a redução da pena pela metade. Nesse sentido, anoto que a quantidade da droga encontrada com o sentenciado desautoriza a redução da pena em fração menor. Destarte, fixo a reprimenda final em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR oos réus DIEGO LUCIANO FERRARI DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE BENEDITO PIMENTA ao cumprimento de 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e ABSOLVÊ-LOS da imputação prevista no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Regime inicial de cumprimento de pena: Como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.C § 3º do mesmo artigo.

Considerada a quantidade da pena, a primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena será cumprida no regime aberto, salvo regressão. Substituição por pena restritiva de direitos: Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do do Código Penal.

Assim, presentes os requisitos legais, substituo as penas privativas de liberdade de ambos sentenciados por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços em entidade indicada em sede de execução, bem como ao pagamento de pena pecuniária no valor de um salário mínimo e meio, para cada sentenciado.

Da destinação dos bens apreendidos:

Decreto o perdimento da quantia de R\$ 500,00 em favor da União, tendo em vista que sua origem lícita não restou demonstrada por nenhum elemento constante nos autos. Por outro lado, determino a restituição dos aparelhos celulares das marcas Apple e Samsung aos sentenciados, tendo em vista que não há nenhum elemento nos autos que conduza à compreensão de que foram utilizados na prática da traficância.

Além disso, determino o perdimento do veículo apreendido, pois foi utilizado para a prática do crime.

Finalmente, determino a destruição da droga e das embalagens apreendidas.

Prisão preventiva: é caso de revogação, porquanto o regime para cumprimento da pena fixado na sentença foi o aberto, incompatível com a segregação cautelar. Assim, expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos dos sentenciados (CF, art. 15, inc. III);

2) Intimem-se os sentenciados para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA